

1500056-71.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) embalagens plásticas contendo a droga cocaína, bem como tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, mais 14 (quatorze) embalagens contendo a mesma droga, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500056-71.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-71.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WÉSLEY CUSTÓDIO JANUÁRIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Wesley Custódio Januário foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Amábile Marangoni, nº 137, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) embalagens plásticas contendo a droga cocaína, bem como tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, mais 14 (quatorze) embalagens contendo a mesma droga, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado, por defensor constituído, apresentou defesa prévia (fls. 71/72) e a denúncia foi recebida aos 17 de maio de 2022 (fls. 83/84).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

O representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da prova produzida, pois decorrente de

diligência empreendida por guardas civis municipais. No mérito requer a improcedência da ação penal e, no caso de condenação, postula benesses quanto à pena aplicável, com afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Deve ser rechaçada a alegada nulidade decorrente da prisão efetuada pelos guardas civis municipais, pois, no caso dos autos, não apenas os guardas civis, mas qualquer do povo estava autorizado a realizar a prisão em flagrante, não havendo que se falar em nulidade capaz de gerar o relaxamento da prisão.

De se pontuar que a ação teve início fora da residência do acusado, onde foi realizado a abordagem e os guardas civis já localizaram 23 porções de cocaína na posse do agente, o que autorizava o ingresso em sua residência, especialmente porque, como afirmado por ambos os servidores públicos, a incursão na casa foi autorizada pelo acusado, inexistindo prova em sentido contrário. Nesse sentido, em recente precedente, a Egrégia 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que:

Não se sustenta a tese de nulidade da prova sob argumento de que os guardas civis não possuem atribuição de polícia judiciária ou de investigação criminal. Com efeito, embora constitucionalmente seja atribuída à polícia civil a função de polícia judiciária e à polícia militar o policiamento ostensivo, as guardas civis municipais, instituídas por leis com permissivo do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, exercem atividades de policiamento, com dever de manutenção da ordem pública e zelo da segurança dos munícipes. Assim sendo, no exercício de suas funções, os guardas civis metropolitanos que constatarem atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 667.413 SP, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/06/2021). "Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Explico. Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo. (...) Ainda, tem-se que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, a Guarda Municipal, verbis: "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." Apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas a proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis: "Art. 301.

Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante no caso concreto. Portanto, não há falar, em situações como tais, em inexistência de denúncia anônima, de mandados de prisão, assim como dos de apreensão de material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância. (STJ, Habeas Corpus nº 650.864 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Decisão Monocrática, j. 21/05/2021).

(Apelação Criminal n. 1501969-26.2020.8.26.0567, Relator Desembargador Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal).

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15); pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16); pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 43/45), laudo pericial de local de crime (fls. 46/53) e por toda a prova oral colhido em juízo.

Edmar da Silva Fernandes disse que recebeu denúncia anônima de indivíduo praticando tráfico de drogas na Rua 13, no Bairro Santa Terezinha. Deslocou-se ao local e avistou o acusado saindo de sua residência, o qual ao avistar a guarnição, ergueu as mãos e foi revistado, localizando 23 pinos em sua mão. Questionado, o acusado disse que havia mais drogas no interior de sua casa e, no local indicado por ele, encontrou 14 pinos de pó branco dentro do banheiro, em um cesto de roupa suja indicado pelo increpado. Em seguida, em outro local, encontrou dinheiro que, segundo o acusado, era proveniente do tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Carlos Eduardo Justino da Silva.

Em solo policial, o acusado reservou-se ao direito constitucional de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo.

Em juízo, o acusado teve a revelia decretada.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar a dinâmica relatada pelos guardas civis, que avistaram o acusado em local já conhecido pela venda de drogas.

Se isso não bastasse, os guardas civis confirmaram que o acusado, durante a abordagem, confirmou que as porções eram destinadas à comercialização, saltando aos olhos, ainda, a apreensão de expressiva quantia de dinheiro de origem lícita não comprovada.

Desse modo, inegável que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não

haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Nem se diga que o acusado praticava o tráfico de drogas para sustentar seu vício, pois não há prova nenhuma que indique tratar-se de usuário contumaz, apenas a sua alegação.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal, já que a quantidade apreendida não destoa significativamente do que normalmente se vê em casos semelhantes.

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuante a reconhecer.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial do local revela que nas imediações está localizada praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que o estabelecimento de ensino seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Em terceira fase, entendo possível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, com redução da pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 193 dias-multa.

Em razão da quantidade imposta, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, pois esse é entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu Habeas Corpus coletivo para proibir que os juízes e desembargadores da Justiça de São Paulo apliquem regime fechado a presos enquadrados no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), estendendo, inclusive, aos condenados que já cumprem pena nessa situação, conforme

a seguinte ementa:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1)."

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Wesley Custódio Januário à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma da fundamentação.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fls. 54), pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 08 de novembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA